

伝聞証拠に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 証人が公判期日において、前に裁判官の面前でした供述と異なった供述をした場合、前にした供述を録取した書面で供述者の署名又は押印のあるものは、公判期日における供述よりも前にした供述を信用すべき特別の情況の存するときに限り、これを証拠とすることができる。
- イ. 火災原因の調査、判定に関し特別の学識経験を有する私人が、弁護人の依頼を受けて燃焼実験を行ってその考察の結果を報告した書面は、裁判所から鑑定を命じられた者が作成した鑑定の経過及び結果を記載した書面と同じ要件のもとでこれを証拠とすることができる。
- ウ. 刑事訴訟法第323条第2号によれば、「業務の通常の過程において作成された書面」は、その作成者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときに限り、これを証拠とすることができる。
- エ. 甲の検察官に対する供述調書中に、被告人乙が甲に対してした「V方に放火してきた。」旨の供述が含まれているときは、刑事訴訟法第321条第1項第2号及び同法第324条により、これを乙の現住建造物等放火被告事件において証拠とすることができる。
- オ. 刑事訴訟法第325条による書面に記載された供述が任意にされたものかどうかの調査は、必ずしもその証拠調べの前にされなければならないものではない。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ オ 4. ウ エ 5. エ オ

ア 誤っている

裁判官の面前における供述を録取した書面を裁判官面前調書という（321 条 1 項 1 号）。公判における供述が裁判官面前調書の供述と反する場合、321 条 1 項 1 号後段により、調書の供述の信用性を問題とすることなく、調書に証拠能力が認められる。その理由は、被告人に実質的に反対尋問の機会が与えられている上、裁判官の面前でされた供述であるところに信用性の情勢的保障があるためである。

イ 正しい ★

最決平 20.8.27（百選 83 事件）は、非現住建造物等放火罪に係る火災の原因に関する「燃焼実験報告書」と題する書面の抄本（以下「本件報告書抄本」という。）が、その作成者の証人尋問の後に、321 条 3 項により採用されたという事案において、「同項所定の書面の作成主体は『検察官、検察事務官又は司法警察職員』とされているのであり、かかる規定の文言及びその趣旨に照らすならば、本件報告書抄本のような私人作成の書面に同項を準用することはできない」とした上で、「上記証人尋問の結果によれば、上記作成者は、火災原因の調査、判定に関して特別の学識経験を有するものであり、本件報告書抄本は、同人が、かかる学識経験に基づいて燃焼実験を行い、その考察結果を報告したものであって、かつ、その作成の真正についても立証されていると認められるから、結局、本件報告書抄本は、同法 321 条 4 項の書面に準ずるものとして同項により証拠能力を有する」としている。

ウ 誤っている ★

323 条 2 号は、「前 3 条に掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。」と規定し、同条 2 号は「商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面」を挙げている。このような書面は、業務の過程で機械的・継続的に作成され類型的に信用性が高いため、反対尋問を経ることなく、無条件に証拠能力を認めることとしたのである。よって、323 条 2 号によれば、「業務の通常の過程において作成された書面」は、その作成者が公判期日において証人として反対尋問を受けていないときであっても、無条件でこれを証拠とすることができる。

エ 正しい

最判昭 32.1.22（百選 86 事件）は、被告人甲の検察官に対する供述調書中に共同被告人乙からの伝聞の供述が含まれている場合に、これを被告人乙に対する証拠とすることができるかが問題となった事案において、「原审が……刑訴 321 条 1 項 2 号及び同 324 条により右供述調書中の所論の部分についての証拠能力を認めたことは正当である」としている。その理由として、判例は、「この場合反対尋問をなすべき地位にある者は被告人乙であり、反対尋問をされるべき地位にある原供述者もまた被告人乙であるから、結局被告人乙には憲法 37 条 2 項の規定による原供述者に対する反対尋問権はないわけである。従つてその権利の侵害ということもありえないことは明白である（被告人乙は、欲すれば、任意の供述によつてその自白とされる供述について否定なり弁明なりすることができるのであるから、それによつて自らを反対尋問すると同一の効果をあげることができるのである）」ということを挙げている。

オ 正しい

最決昭 54.10.16（百選 A40 事件）は、325 条による書面に記載された供述が任意にされたものかどうかの調査の時期について、「刑訴法 325 条にいう任意性の調査は、任意性が証拠能力にも関係することがあるところから、通常当該書面又は供述の証拠調べに先立つて同法 321 条ないし 324 条による

証拠能力の要件を調査するに際しあわせて行われることが多いと考えられるが、必ずしも右の場合のようにその証拠調べの前にされなければならないわけのものではなく、裁判所が右書面又は供述の証拠調べ後にその証明力を評価するにあたってその調査をしたとしても差し支えない」としている。その理由として、判例は、「刑訴法 325 条の規定は、裁判所が、同法 321 条ないし 324 条の規定により証拠能力の認められる書面又は供述についても、さらにその書面に記載された供述又は公判準備若しくは公判期日における供述の内容となつた他の者の供述の任意性を適当と認める方法によつて調査することにより……、任意性の程度が低いため証明力が乏しいか若しくは任意性がないため証拠能力あるいは証明力を欠く書面又は供述を証拠として取り調べて不当な心証を形成することをできる限り防止しようとする趣旨のもの」と解される」ということを挙げている。

以上により、誤っている記述はアとウであり、したがって、正解は肢2となる。

